

1501743-39.2019.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/03/2022

... atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501743-39.2019.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2251602/2019 - 04º D.P. MAUA, 7118047 - 04º D.P. MAUA, 1335/2019 - 4º Distrito Policial de Mauá, 2251602 - 04º D.P. MAUA, 1335/19/206 - 04º D.P. MAUA, 2251602 - 04º D.P. MAUA, 1335/19/206 - 04º D.P. MAUA, 2251602 - 04º D.P. MAUA, 1335/19/206 - 04º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ALAN FERREIRA DA SILVA

Data da Audiência:

25/03/2022

Justiça Gratuita

Em 25 de março de 2022 às 15h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o cusado e a Defensora reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr.

Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu José Alan Ferreira da Silva. Presente a Advogada, Dra. Thayna Ângelo Nazário (OAB/SP 449.362). Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. JOSÉ ALAN FERREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 8/9 e 36, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de agosto de 2019, por volta de 10h:29min, na Rua Júlio Antônio Condé, nº 70, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, transportava, para entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) sacola plástica contendo 61,3 gramas de cocaína (Item 1), e 01 (um) microtubo plástico tipo Eppendorf contendo 0,4 gramas de cocaína (Item 2), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, laudo de constatação de fls. 33/35 e laudo toxicológico de fls. 90/92 (fls. 129/131). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 47/49). A defesa do réu José impetrou habeas corpus com pedido de concessão liminar (fls. 60/70), o que foi deferido parcialmente pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo expedido alvará de soltura (fls. 71/75). A denúncia foi oferecida (fls. 128). O réu foi notificado (fls. 160) e apresentou defesa preliminar (fls. 168/169). A denúncia foi recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 174/179 e 218/220). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Claudio Bezerra da Silva (fls. 218/220), Hugo José Suzart Alves Rodrigues (fls. 218/220) e Erivelton Torres Silva (fls. 218/220), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Jose Alan Ferreira da Silva (gravação audiovisual). Nesta audiência, as desistiram das oitivas das testemunhas Denis do Nascimento Santos e Minegilda Izabel Ferreira da Silva, e o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Erivelton Torres Silva (fls. 218/219). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Claudio Bezerra da Silva (fls. 2), Hugo José Suzart Alves Rodrigues (fls. 3), Erivelton Torres Silva (fls. 4), Pedro Henrique Telles Santos (fls. 5), Denis do Nascimento Santos (fls. 6) e Minegilda Izabel Ferreira da Silva (fls. 7) e o réu Jose Alan Ferreira da Silva (fls. 8/9). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu José, em debates, requereu a improcedência da ação (gravação audiovisual). Auto de exibição e apreensão (fls. 25/26). Laudo de constatação provisória (fls. 33/35). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 90/92 e 110/112). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 93/94). Laudo de exame no veículo (fls. 103/109). Laudo de exame nos aparelhos celulares (fls. 121/124). Folha de antecedentes (fls. 149/151 = 209/211) e certidão (fls. 42/44). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), laudo de constatação provisória (fls. 33/35), exame químico toxicológico definitivo (fls. 90/92), laudo de exame de corpo de delito (fls. 93/94), laudo de exame no veículo (fls. 103/109), laudo de exame nos celulares (fls. 121/124) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Claudio Bezerra da Silva disse que: a) estava em patrulhamento de bicicleta, quando

avistamos um GM Corsa com quatro indivíduos no interior e eles apresentaram nervosismo; b) em busca pessoal nada foi localizado; c) em revista no interior do Corsa, no assoalho do lado dianteiro do passageiro, havia uma mochila com entorpecente e uma quantia em dinheiro; d) o Senhor Erivelton conduzia o indivíduo e ele negou que a mochila era dele, foi quando o Senhor José assumiu a propriedade da mochila; e) na mochila, foi encontrada cocaína, mas não me recorde a quantidade, e dinheiro, também não me recorde a quantia; f) José disse que estava em uma festa vendendo e pediu carona para eles; g) o nervosismo é comum, o que levou a abordagem foi o nervosismo demasiado; h) o carro estava em movimento, com quatro indivíduos, mas não me lembro se o vidro estava aberto; i) Erivelton estava conduzindo o veículo, José era o passageiro do banco da frente, o Denis estava no banco traseiro e mais um que não me recorde o nome, acho que o Pedro; j) depois disse que na parte de trás estavam o Pedro e o Bruno (fls. 2 e 218/220). A testemunha Hugo José Suzart Alves Rodrigues, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos em patrulhamento com as motos e passou um veículo, cor bege, meio dourada, cuja marca não me recorde; b) em revista pessoal nada foi encontrado; c) em revista no veículo foi encontrada uma mochila no assoalho do banco dianteiro do passageiro; d) na mochila foi encontrada uma porção embalada em uma sacola, um pino com cocaína que ele estava usando e vários eppendorff's vazios que ele disse que iria para outra festa e embalaria aquela certa quantia que estava na trouxa com ele; e) o Alan disse que a mochila era dele; f) quem dirigia era o Denis e o José estava no banco da frente dormindo, não me recorde os nomes dos dois que estavam atrás; g) os demais disseram que não sabiam o que havia na mochila e deram carona a ele de uma festa; h) acho que quem apareceu lá foi a família do motorista; i) o veículo estava em movimento no contra fluxo, nós estávamos indo na Avenida Castelo Branco e eles iam sentido bairro; j) para mim o motorista era o Denis, porque o veículo estava no nome dele; k) a mochila estava no assoalho do banco da frente do passageiro, onde o Alan estava sentado; l) era um GM Corsa; m) não conhecia nenhuma das quatro pessoas abordadas; n) nós os abordamos, porque o carro estava rápido e era dia de feira (fls. 3 e 218/220). Judicialmente, a testemunha Erivelton Torres Silva disse que: a) acho que foi em 2019, não me lembro o mês direito; b) nós estávamos em uma balada e o meu primo pediu carona; c) os policiais nos abordaram e falaram que encontraram drogas; d) eu não estava dirigindo o veículo e não me lembro quem dirigia; e) o José Alan estava no banco da frente; e) eu não vi se os policiais encontraram drogas, eu não acompanhei a revista feita no veículo; f) não me recorde das outras pessoas que estavam presentes; g) não me recorde se o José Alan tinha uma mochila com ele; h) me levaram para trás do veículo com outra pessoa e não via eles realizarem a revista no veículo (fls. 4 e 218/220). Por fim, o réu José Alan Ferreira da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu não estava com a mochila com as drogas; b) fui ameaçado pelo Delegado de Polícia; b) eu conheço o Erivelton e dentro do carro não havia nenhuma polícia; c) eu já havia sido abordado pelos policiais outras vezes; d) eu não tenho nada contra os policiais e acho que eles não gostam de mim; e) eu entregava marmitex, não parei a moto e dei fuga, acho que não me bateram, porque haviam moradores (gravação audiovisual e fls. 8/9). Pois bem, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), laudo de constatação provisória (fls. 33/35), exame químico toxicológico definitivo (fls. 90/92), laudo de exame de corpo de delito (fls. 93/94), laudo de exame no veículo (fls. 103/109), laudo de exame nos celulares (fls. 121/124), como também pelos depoimentos das testemunhas Claudio Bezerra da Silva (fls. 2 e 218/220), Hugo José Suzart Alves Rodrigues (fls. 3 e 220), Erivelton Torres Silva (fls. 4 e 218/220), Denis do Nascimento Santos (fls. 6) e Minegilda Izabel Ferreira da Silva (fls. 7), os dois últimos que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa do réu José Alan Ferreira da Silva (gravação audiovisual e fls. 8/9), foi

comprovado que as testemunhas Claudio e Hugo, que são policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o veículo GM/Corsa, placas DRK-7326, e os abordaram diante do nervosismo deles e da velocidade que era impressa no veículo. Em revista pessoal nada foi encontrado com eles, mas em revista no veículo, no interior de uma mochila que estava no assoalho do banco do

passageiro dianteiro, local em que o réu se encontrava foi apreendida uma mochila que continha 1 porção de cocaína, pesando 61,3g, e 1 eppendorf de cocaína, pesando 0,4g, além de 45 eppendorfs vazios, além da quantia de R\$ 55,00. A autodefesa restou isolada nos autos e sem credibilidade, porque o réu alterou a versão de que havia dado na fase extrajudicial (fls. 8/9). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Jose Alan Ferreira da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (1 porção de cocaína, pesando 61,3g, e 1 eppendorf de cocaína, pesando 0,4g - fls. 25/26, 33/35 e 90/92) não permitem aumentar a pena, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 42/44 e 149/151 = 209/211). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Não reduzirei a pena em face da menoridade do réu (fls. 1 e 8/9), pois a pena ainda se encontra no seu patamar mínimo, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz "na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" - (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59 do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente (fls. 42/44 e 149/151 = 209/211), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (1 porção de cocaína, pesando 61,3g, e 1 eppendorf de cocaína, pesando 0,4g - fls. 25/26, 33/35 e 90/92), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de

que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempo pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. 5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (62 porções de cocaína, contendo 55,63g; 04 pedras de crack, contendo 0,41g; e 63 porções de "maconha", contendo 132,64g) , utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. Habeas corpus não conhecido." - (grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a aplicou a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 18,7g de cocaína e 348,5g de Cannabis sativa - constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no

caso o semiaberto.

3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido." - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art.33, § 3º, do Código Penal, e do art.42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (195,6g maconha, 63,9g de cocaína, 17,1g de crack e mais 118g de cocaína) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação." - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.

Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena do réu, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (1 porção de cocaína, pesando 61,3g, e 1 eppendorf de cocaína, pesando 0,4g - fls. 25/26, 33/35 e 90/92), fato concreto que impede a substituição. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 8/9). Os tubetes plásticos (fls. 25/26), foram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, porque eles são utilizados para acondicionar as drogas (no caso dos tubetes), porque eles estavam sendo utilizados para comunicação dos traficantes (no caso dos telefones celulares) ou porque ele estava sendo utilizado para o transporte das drogas (no caso do veículo) (fls. 10/13, 25/26 e 33/35), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de serem bens lícitos não foram reclamados por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que os objetos sejam destruídos, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei n.º 11.343/2006. Caso o contrário oficie-se ao FUNAD para que ele se aposse do bem. Não determinei a perda dos telefones celulares e do veículo apreendidos, porque não pertencem ao réu (fls. 11/12 e 25/26) Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 25/26), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, determino desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 25/26, 33/35 e 90/92). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO os réus JOSÉ ALAN FERREIRA DA SILVA (R.G. nº 57.921.497-SP - filho de José Airton da Silva Filho e Maria José Ferreira da Silva - fls. 8/9 e 36), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. fls. 71/75 e 76/78). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objeto apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual

contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; f) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Ministério Público, pela Defesa e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de

recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo os recursos requeridos pelo Ministério Público e pela Defesa. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas à Defesa para apresentação de contrarrazões e razões. Após vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. Saem os presentes intimados." NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.